

1502087-27.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... - certidão de pp 56 e 57), um crime de tráfico de drogas (autos n.º 0007679-49.2002.8.26.0562 - certidão de pp. 57/58) e outro crime de porte ilegal de drogas (autos n.º 0008248-21.2000.8.26.0562 - certidão de p. 58), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, maculam sua vida pregressa e deixam claro que a situação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502087-27.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502087-27.2022.8.26.0536 - Controle n.º 505/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO RICARDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

SERGIO RICARDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 11 de junho de 2022, por volta das 20h, na Avenida Pedro Lessa, neste município e comarca, tentou subtrair, para si, a bicicleta pertencente a Hudson Augustus Souza Aparecido. Para isso, ameaçou gravemente as vítimas Hudson e Reginaldo Gonçalves com a promessa de ferir. O acusado empregou uma arma branca (faca) na execução do crime e violência física contra Reginaldo Gonçalves.

Diz a denúncia que vítima Hudson estacionou sua bicicleta na via pública, imobilizando-a com uma corrente e cadeado. Logo após, o acusado foi até lá com o objetivo de subtrair a bicicleta. Ele tinha um alicate de corte, ferramenta que seria usada para romper a corrente que prendia a bicicleta. No instante em que começou a cortar a corrente, o acusado foi surpreendido por Hudson e seu pai Reginaldo. Então, pretendendo levar adiante a subtração do bem e garantir a fuga, o acusado sacou uma faca e a exibiu para as vítimas. Com isso, transmitiu aos ofendidos a ideia de que iria feri-los caso tentassem impedir a subtração e evitar a sua fuga.

Contudo, as vítimas não se intimidaram e foram em direção ao acusado. Ele fugiu sem levar o bem que desejava subtrair. Na fuga, o acusado apanhou um pedaço de madeira

e golpeou o ofendido Reginaldo, ferindo-o. Mesmo assim, as vítimas conseguiram deter o acusado e solicitaram o auxílio da Polícia Militar. O acusado foi preso em flagrante. O bem vale R\$ 800,00.

Diz, por fim, a petição inicial que, interrogado pela autoridade policial, o acusado afirmou o seguinte: "estava caminhando pelo local dos fatos, mas não tentou subtrair a bicicleta, apenas ela caiu quando passou perto, momento em que dois indivíduos vieram em sua direção alegando que teria tentado furtar a bicicleta. Declarou que trazia um alicate lábios de mel para subtrair fios de cobre, mas não a bicicleta. Declarou que os indivíduos vieram em sua direção e, para se defender, usou a faca que trazia na mochila. Declarou que foi agredido por um pedaço de madeira pelos donos da bicicleta" (pp. 82/84).

Recebida a denúncia (pp. 85/86), foi o réu citado pessoalmente (p. 98). A Defesa ofereceu a resposta de p. 102, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 103/104).

Na instrução foram ouvidas uma vítima e duas testemunhas. As partes requereram e tiveram homologada a desistência das declarações da outra vítima, procedendo-se, a seguir, ao interrogatório (pp. 135/136).

Em alegações finais orais, o Ministério Público aditou a denúncia para constar que o crime teve o início de sua execução na Rua Frei Francisco Sampaio, em frente ao número 73, local onde a bicicleta da vítima estava estacionada e imobilizada, sendo o final da execução do delito na Avenida Pedro Lessa, segundo descrito na denúncia, local no qual o acusado foi preso. No mérito, requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial e seu aditamento. Pretendeu a fixação da pena acima do mínimo legal e a aplicação do regime inicial fechado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. Por fim, pleiteou a aplicação da causa de diminuição da pena relativa à tentativa em seu patamar máximo, pois a conduta do réu foi interrompida logo no início da execução do crime (gravação audiovisual, pp. 135/136).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, sustentando não estar comprovada a autoria, uma vez que o réu negou a prática delitiva, os policiais militares não presenciaram os fatos e a vítima não foi capaz de reconhecer o acusado em juízo. Subsidiariamente, pretendeu a desclassificação para reconhecimento da ocorrência de crimes de furto tentado e ameaça, alegando que o acusado teria tentado subtrair a bicicleta, sem conseguir a posse do bem. Ainda, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa à tentativa e sua aplicação no patamar máximo legal (gravação audiovisual, pp. 135/136).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, fica expressamente consignado que é caso de receber o aditamento oferecido pelo Ministério Público em suas alegações finais orais, para fazer constar que o fato aqui apurado ocorreu na Rua Frei Francisco Sampaio, em frente ao número 73, nesta cidade, e não na Avenida Pedro Lessa, evidenciando-se erro material na denúncia.

No mérito, o pedido na inicial é procedente em parte.

A materialidade está satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de p. 18.

A autoria dos fatos delituosos também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o acusado afirmou que estava caminhando pelo local, mas não tentou subtrair a bicicleta, que caiu quando passou perto dela. Nesse momento, dois indivíduos vieram em sua direção afirmando que teria tentado furtar a bicicleta. Declarou que trazia um alicate lábios de mel para subtrair fios de cobre, mas não a bicicleta. Contou que os indivíduos vieram em sua direção e, para se defender, usou a faca que trazia na mochila. Foi agredido com um pedaço de madeira pelos donos da bicicleta (p. 14).

Em juízo, ao ser interrogado, declarou que já foi condenado duas vezes por roubo e possui penas a cumprir. Contou que estava caminhando por uma travessa da Avenida Pedro Lessa e duas pessoas passaram correndo, cada uma delas seguindo por um caminho diferente. Os policiais pensaram que era o autor do crime e vieram em sua direção. Foi agredido fisicamente pelos policiais. Afirmou que não visualizou a

bicicleta. Trazia nas costas uma mochila na qual guardava uma pequena faca de serra que utilizava para cortar fios de cobre. Esclareceu que foi detido por populares em frente a um posto de combustível na Avenida Pedro Lessa. Correu das pessoas que vieram com pedaços de madeira para agredi-lo e se armou com a faca que trazia na mochila apenas para se defender. Não sabe quem agrediu a vítima. Informou que se encontrava em situação de rua e costumava permanecer naquela região. Estava “em liberdade” há dois anos e meio, cumprindo pena em regime aberto. Recebia o benefício governamental do Auxílio Brasil. É solteiro e possui dois filhos maiores. Trabalhava recolhendo materiais recicláveis e como ajudante na feira. É viciado em crack há mais de vinte anos. cursou até a quinta série do ensino fundamental. Admitiu que trazia consigo um alicate lábios de mel para cortar fios de cobre que estivessem jogados na via pública (gravação audiovisual, pp. 135/136).

E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.

H.A.S.A. contou que o fato se deu na Rua Frei Francisco Sampaio. Disse que tinha o costume de deixar sua bicicleta presa a um poste ao lado da casa de sua família e permanecia vigiando-a pela janela do imóvel. Na ocasião, avistou dois homens passando com sacolas nas mãos, aparentando serem coletores de latas de alumínio, e suspeitou deles. Continuou observando os dois indivíduos e presenciou que um deles virou na Avenida Pedro Lessa e voltou ao local onde estava estacionada a bicicleta. Este homem mexeu na bicicleta e cortou a corrente dela com uma faca. Assim, foi até a rua acompanhado de seu pai e disse ao homem que ele deveria se entregar e que chamaria a Polícia. Ato contínuo, o agente os ameaçou com a faca e correu em sentido à Avenida Pedro Lessa. Esclareceu que o homem estava com um alicate lábios de mel e uma faca, mas não chegou a cortar a corrente da bicicleta. Ele já havia tentado cortar a corrente com a faca e foi surpreendido no momento que utilizaria o alicate. Ao ser descoberto, o indivíduo se armou com a faca, ameaçou-os e correu em direção à Avenida Pedro Lessa. Nesta avenida conseguiu derrubar e imobilizar o criminoso. Afirmou que seu pai foi agredido na mão com o alicate lábios de mel. Disse que seu prejuízo foi em relação à corrente da bicicleta, que foi cortada pelo homem. Em audiência por videoconferência, ao observar o acusado – identificado com a placa número 1 – e os outros dois detentos colocados para reconhecimento – identificados com as placas números 2 e 3 –, apontou o homem que segurava a placa número 3. Mostradas as imagens da audiência de custódia, nelas reconheceu o acusado como sendo o autor do fato aqui apurado. Disse que, por ocasião da audiência de custódia, o réu vestia roupas semelhantes às aquelas que o autor da ação trajava (gravação audiovisual, pp. 135/136).

Maira de Oliveira Mendes, policial militar, narrou que ela e seu parceiro estavam em patrulhamento pela Avenida Pedro Lessa quando foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência de roubo, na qual o autor do crime já havia sido detido pelas vítimas e populares. Assim, dirigiram-se até o local indicado e encontraram as vítimas, alguns populares e o acusado detido pelo furto de uma bicicleta ocorrido na Rua Frei Francisco Sampaio. Segundo o relato da vítima, o acusado teria tentado abrir o cadeado da bicicleta que estava presa a um poste. Ao ser surpreendido, o réu sacou uma faca para tentar agredir a vítima e os dois entraram em luta corporal. Contou que sua equipe apreendeu uma faca e um alicate lábios de mel na ocasião. O acusado foi levado ao pronto socorro por estar com algumas escoriações e nada declarou sobre o fato. O ofendido também apresentava escoriações (gravação audiovisual, pp. 135/136).

Daniel Soares de Lima, policial militar, referiu que sua equipe estava em patrulhamento quando foram acionados via COPOM sobre um indivíduo que havia sido detido por ter praticado um roubo. Chegando ao local, constataram que se tratava de uma tentativa de furto, em que o acusado havia tentado subtrair a bicicleta presa ao poste utilizando um alicate lábios de mel. O ofendido teria observado da ação delituosa pela janela e foi falar com o réu. Os dois entraram em luta corporal e o acusado puxou uma faca para agredir a vítima. Confirmou a apreensão do alicate lábios de mel e da faca. O réu nada declarou e aparentava estar sóbrio (gravação audiovisual, pp. 135/136).

R.G., ouvido apenas na fase extrajudicial, declarou que estava em seu apartamento

com seu filho Hudson, momento em que recebeu uma ligação de sua filha Sabrina, que havia acabado de sair do apartamento, informando que dois indivíduos estariam em atitude suspeita rondando o local, aparentemente olhando para a bicicleta de Hudson que estava presa ao poste em frente ao prédio. Contou que desceu com Hudson e viram dois indivíduos passando e aguardaram. Em seguida, um deles retornou e, com o uso de um alicate lábios de mel que trazia nas mãos, tentou romper o cadeado que prendia a bicicleta, momento em que se dirigiram até o local para impedir e abordar o rapaz. Referiu que o indivíduo passou a dizer que estava armado e apontou uma faca pequena em sua direção e de seu filho em tom de ameaça. Ele tentou fugir, mas foram ao seu encalço. Declarou que o indivíduo virou na primeira rua à direita, Rua Galeão Coutinho, em direção à Avenida Pedro Lessa, oportunidade em que o fugitivo pegou um pedaço de madeira que havia numa lixeira e veio em sua direção e de seu filho, descartando a faca no local. Narrou que seguiram em perseguição, abordando o indivíduo apenas na Avenida Pedro Lessa, momento em que ele desferiu um golpe com o pedaço de madeira em sua mão e foi prontamente detido por seu filho até a chegada da Polícia Militar, acionada por populares. Negou ter agredido o indivíduo, afirmando que apenas empregaram a força necessária para detê-lo. Disse que sofreu uma lesão na mão esquerda em virtude do golpe desferido pelo autor do crime, mas não sabe dizer se o golpe foi efetuado com o uso do alicate ou do pedaço de madeira (p. 12).

Vê-se, assim, que ao contrário do que sustentou a Defesa, a prova amealhada é segura e dá suporte ao desate condenatório.

Ao que aqui se apurou, a vítima Hudson havia deixado sua bicicleta presa ao poste de iluminação com uma corrente e cadeado. Em dado momento, ele avistou dois homens suspeitos passando pelo local e observou quando um deles voltou ao ponto onde estava estacionada a bicicleta.

Consta que o criminoso mexeu na bicicleta e tentou cortar com uma faca a corrente que a prendia, mas foi surpreendido pelo ofendido Hudson e seu pai Reginaldo no momento em que usaria o alicate tipo "lábios de mel" para romper a corrente.

Apurou-se que os dois determinaram que o homem se rendesse pois chamariam a Polícia, mas o criminoso os ameaçou com a faca e correu em sentido à Avenida Pedro Lessa. O agente golpeou a mão do ofendido Reginaldo, mas foi derrubado e imobilizado pelo proprietário da bicicleta.

Ao que se viu da prova colhida, imediatamente após os fatos, o acusado foi perseguido e detido pelos ofendidos Hudson e Reginaldo, tendo sido reconhecido por eles, que naquela ocasião tinham as melhores condições de identificar aquele que havia acabado de tentar subtrair a bicicleta e que os ameaçou com uma faca.

Ademais, e mostradas ao ofendido Hudson, em juízo, as imagens registradas nos autos da audiência de custódia do acusado, a vítima afirmou que o réu, nessa ocasião, vestia roupas semelhantes às trajadas pelo autor da ação delituosa.

Neste ponto, registre-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou quanto ao procedimento de reconhecimento com base na gravação da audiência de custódia, no sentido de que "supondo que a vítima reconheça ou não o acusado pessoalmente, tanto qualquer das partes e sujeitos do processo – defesa, acusação e o próprio magistrado – podem mostrar a ela, em audiência, as imagens registradas nos autos e questioná-la se reconhece ou não a pessoa nelas retratada" (TJSP; Apelação Criminal 0001045-54.2017.8.26.0548; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2018).

Assim, não compromete a prova aqui reunida o fato do ofendido Hudson não ter apontado o acusado quando se procedeu ao reconhecimento pessoal na fase judicial, uma vez que não há dúvida de que o réu é a pessoa que foi perseguida e detida pelas vítimas logo após ter sido flagrado por elas tentando subtrair a bicicleta.

Imperioso observar, ainda, que o acusado apresentou versão contraditória, havendo sugestiva incongruência entre o dito na delegacia e o afirmado em juízo, uma vez que, perante a autoridade policial, declarou que a bicicleta do ofendido caiu no chão quando passou ao lado dela, enquanto que, em sede judicial, disse que sequer viu a bicicleta da vítima, o que certamente compromete o crédito que se poderia dar as suas afirmações.

À vista da prova aqui reunida, por todo o exposto, patente e inegável é que o

acusado é o autor do crime descrito na denúncia e seu aditamento.

Inegável também que se tratou de subtração tentada, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, que se viu surpreendido pelo proprietário da bicicleta e seu pai.

Entretanto, é de se atender os reclamos da Defesa quanto à desclassificação do crime, pois não há prova segura que indique que o acusado tenha empregado ameaça e violência física para concretizar a subtração.

As declarações dos ofendidos e o contexto em que se deram os fatos demonstram que o acusado ameaçou as vítimas com a finalidade de fugir do local.

Ao que aqui se apurou, a bicicleta estava presa pela corrente ao poste de iluminação pública e o acusado, após a chegada dos ofendidos, não tentou, de nenhum modo, soltá-la a fim de concretizar a subtração, mas apenas se valeu de ameaça e violência visando desvencilhar-se deles, tanto que o réu correu e foi perseguido pelo proprietário da bicicleta e seu pai.

Ainda que demonstrada a existência de ameaça e violência, é possível concluir que foram empregadas pelo agente após a tentativa de subtração com o intuito de assegurar a sua fuga livremente, e não para conseguir a posse da res furtiva, não se podendo falar em roubo próprio.

Extrai-se da lição de Rogério Sanches Cunha que "se o agente é surpreendido quando, sem violência, ia apoderar-se da coisa, frustrando-se a subtração, mas a vem empregar na fuga, há tentativa de furto (e não de roubo), em concurso material com o crime contra a pessoa (lesão corporal, homicídio etc)" (Manual de Direito Penal: parte especial. 12 ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 315).

De igual modo, Victor Eduardo Rios Gonçalves comenta: "Assim, se o agente entra em uma casa para praticar um furto e antes de se apoderar de qualquer objeto surge alguém no local e o agente emprega contra ela violência ou grave ameaça, temos as seguintes possibilidades: a) se a finalidade do agente ao agredir ou ameaçar a vítima é a de concretizar a subtração, responde por roubo próprio porque a violência ou grave ameaça foram empregadas antes de perpetrada a subtração; b) se sua finalidade ao agredir ou ameaçar a vítima é fugir do local sem ser preso, responde por tentativa de furto em concurso material com crime de lesão corporal ou ameaça (agravadas porque empregadas a fim de garantir a impunidade de outro crime – art. 61, II, b, do Código Penal)" (Esquemático - Direito Penal - Parte Especial (p. 427). Saraiva Jur. Edição do Kindle).

Desta forma, forçoso que se reconheça a pretendida desclassificação para o crime de furto tentado em concurso material com o delito de ameaça e a contravenção penal de vias de fato.

Destaque-se que não há como entender caracterizada a qualificadora de rompimento de obstáculo, pois ausente exame pericial do cadeado e da corrente da bicicleta, lembrando-se que nos autos se tem apenas o exame pericial dos objetos apreendidos com o acusado (pp. 87/90).

Na instrução criminal a vítima relatou que o acusado chegou a cortar a corrente da bicicleta com uma faca, mas é certo que esse relato não serve para suprir a falta da prova pericial, exigível quando necessário o exame de vestígios.

É que os vestígios, que formam o corpo de delito, devem ser constatados pela perícia criminal, na forma do disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal, admitindo-se a substituição desse exame quando a falta do exame direto se imputar ao autor do crime.

Assim, a prova pericial - nos termos do previsto no artigo 167 do Código de Processo Penal - só pode suprir a falta da perícia direta quando os vestígios não forem examinados porque desapareceram por culpa imputável ao autor do fato delituoso.

Frise-se que não se está afirmando que a prova oral, nesse aspecto, não seja idônea. É que ela não pode suprir a falta do exame direto, que não foi realizado por razão que não se pode imputar ao réu.

Como ensina Vicente Greco Filho, "...para que a substituição do exame pela prova testemunhal possa ocorrer validamente, porém, é preciso que o desaparecimento dos vestígios seja decorrente de causas não-imputáveis aos órgãos da persecução penal. O exemplo clássico do corpo de delito indireto é o do homicídio com o corpo jogado

ao mar, não sendo possível o exame necroscópico. Se, porém, os vestígios desapareceram em virtude de inércia, inclusive a burocrática, dos órgãos policiais ou judiciais, a menor segurança da prova testemunhal não pode ser carregada ao acusado. Assim, se a vítima de um furto arrombamento, cansada de esperar a visita dos peritos, manda consertar a janela arrombada e, por ocasião do exame, não se constata mais vestígios, a prova testemunhal não pode suprir a falta da perícia. O artigo 167 do Código de Processo Penal, como uma exceção à garantia do acusado quanto à constatação dos vestígios por exame pericial, deve ser interpretado estritamente, impondo que se aplique, exclusivamente, à hipótese de desaparecimento natural, ou por ação do próprio acusado, e não por inércia dos órgãos de persecução penal que atuam contra o eventual réu..." (Manual de Processo Penal, 8ª edição, Editora Saraiva, p. 212).

Reafirme-se que não se tem nos autos o exame pericial do cadeado e da corrente, danificados ou não, situação que impede o reconhecimento da qualificadora.

Assim, é de se reconhecer, tão somente, o crime de furto tentado, em sua forma simples.

De outro lado, não se ignora que o crime de ameaça se procede mediante representação. Entretanto, o direito de representação não exige formalidade legal e pode ser extraído dos relatos das vítimas e do registro do boletim de ocorrência. Neste sentido, leciona Fernando Capez: "a representação prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse do ofendido ou de seu representante legal. Dessa forma, não se exige a existência de uma peça formal, denominada 'representação', bastando que dos autos se possa inferir, com clareza, aquele desígnio do ofendido. Assim, servem como representação as declarações prestadas à polícia pelo ofendido, identificando o autor da infração penal, o boletim de ocorrência etc." (Curso de Processo Penal (pp. 242-243). Saraiva Jur. Edição do Kindle).

E, como já se decidiu:

"...Representação da vítima. Desnecessidade de formalidade especial no ato de representação. Demais elementos comprovam a inequívoca vontade de ver instaurado contra a recorrida investigação policial e ação penal. Precedentes. Recurso não provido." (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0002797-43.2022.8.26.0562; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2022).

De acordo com a prova oral colhida no contraditório, o réu apontou uma faca em direção aos ofendidos Reginaldo e Hudson a fim de ameaçá-los.

As ameaças foram praticadas no mesmo contexto fático, tendo o acusado, mediante uma única ação, ameaçado, individualmente, as duas vítimas, restando caracterizada a intenção de ameaçar cada uma delas, do que se extrai que almejou, dolosamente, a produção de todos os resultados.

Assim, caracterizado está o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do artigo 70 do Código Penal, procedendo-se à somatória das penas cominadas aos delitos.

Por fim, é certo que o acusado golpeou a mão esquerda da vítima Reginaldo com um instrumento, não se sabendo ao certo se utilizou um pedaço de madeira ou um alicate para atingi-la.

Assim, e à vista da ausência de constatação de lesões corporais no ofendido, a conduta se enquadra à contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, em parte, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

O acusado é reincidente, pois definitivamente condenado pelo crime de roubo majorado (autos n.º 0001533-79.2016.8.26.0536 ou 0001908-16.2017.8.26.0158 - certidão de pp. 55/56) e pelo crime de porte ilegal de drogas (autos n.º 0005383-63.2016.8.26.0562 - certidão de p. 57),

Ademais, ostenta condenações definitivas antigas por dois crimes de roubo (autos n.º 0002696-07.2002.8.26.0562 e 0004956-37.2014.8.26.0562 - certidão de pp 56 e

57), um crime de tráfico de drogas (autos n.º 0007679-49.2002.8.26.0562 – certidão de pp. 57/58) e outro crime de porte ilegal de drogas (autos n.º 0008248-21.2000.8.26.0562 – certidão de p. 58), as quais, ainda que não sirvam para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, maculam sua vida pregressa e deixam claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento em prática criminosas.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Destaque-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal também consolidou o entendimento de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, não ocorreu a descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), mas tão somente mera despenalização decorrente da não previsão de pena privativa de liberdade ao usuário de drogas, de forma que a condenação por essa espécie de infração penal torna possível a caracterização de maus antecedentes e reincidência.

Neste sentido:

"ENTORPECENTE – POSSE – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCRIMINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Apesar de despenalizado o crime, não houve a descriminalização da conduta de posse de drogas para consumo pessoal – artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. RECURSO – VOLUNTARIEDADE. A protocolação de recurso submete-se à voluntariedade." (RHC 121584, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, processo eletrônico dje-266 divulg 05-11-2020 public 06-11-2020).

"HABEAS CORPUS" – POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL (LEI Nº 11.343/2006, ART. 28) – INOCORRÊNCIA DE "ABOLITIO CRIMINIS" – SIMPLES MEDIDA DE "DESPENALIZAÇÃO" DESSA CONDUTA – NATUREZA JURÍDICA DE CRIME MANTIDA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR DELITO DESSA NATUREZA COMO CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE PRODUZIR REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (HC 148484 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, processo eletrônico DJe-084 divulg 23-04-2019 public 24-04-2019)

Relativamente ao crime de furto simples tentado, levando em conta os critérios do artigo 59 do Código Penal, em razão dos comprovados maus antecedentes representados por quatro condenações definitivas antigas, sendo duas delas por roubo e uma por crime equiparado a hediondo, aumento a pena-base em 1/4 (um quarto), fixando-a em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência, representada por duas condenações definitivas, sendo uma delas por grave crime de roubo majorado, aumento a pena em 1/5 (um quinto), fixando-a, nesta fase, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelo agente, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 6 (seis) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Em relação ao crime de ameaça praticado contra a vítima Hudson, em razão dos comprovados maus antecedentes representados por quatro condenações definitivas antigas, sendo duas delas por roubo e uma por crime equiparado a hediondo, e das circunstâncias do crime, relacionadas ao uso de uma faca para a intimidação do ofendido, aumento a pena-base em 1/2 (metade), fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Presente a circunstância agravante da reincidência, representada por duas condenações definitivas, sendo uma delas por grave crime de roubo majorado, bem como a agravante por ter o agente cometido o crime para assegurar a impunidade de outro crime, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando-a, nesta fase, em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

No tocante ao crime de ameaça praticado contra a vítima Reginaldo, em razão dos

comprovados maus antecedentes representados por quatro condenações definitivas antigas, sendo duas delas por roubo e uma por crime equiparado a hediondo, e das circunstâncias do crime, relacionadas ao uso de uma faca para a intimidação do ofendido, aumento a pena-base em 1/2 (metade), fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Presente a circunstância agravante da reincidência, representada por duas condenações definitivas, sendo uma delas por grave crime de roubo majorado, bem como as agravantes por ter o agente cometido o crime para assegurar a impunidade de outro crime e contra maior de 60 anos, uma vez que a vítima contava 71 anos de idade à época do fato, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, nesta fase, em 2 (dois) meses de detenção, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Como se viu, há que se entender que os crimes de ameaça foram praticados em concurso formal impróprio.

Desta forma, e nos termos do disposto no artigo 70, segunda parte, do Código Penal, somam-se as penas impostas aos delitos de ameaça, somatória essa que alcança 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Relativamente à contravenção penal de vias de fato praticada contra a vítima Reginaldo, em razão dos comprovados maus antecedentes representados por quatro condenações definitivas antigas, sendo duas delas por roubo e uma por crime equiparado a hediondo, aumento a pena-base em 1/4 (um quarto), fixando-a em 18 (dezoito) dias de prisão simples.

Presente a circunstância agravante da reincidência, representada por duas condenações definitivas, sendo uma delas por grave crime de roubo majorado, bem como a agravante por ter o agente cometido a contravenção penal para assegurar a impunidade de crime, aumento a pena em 1/4 (um quarto), fixando-a, nesta fase, 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Por fim, presente a causa de aumento de pena por ser a vítima maior de 60 anos de idade à época dos fatos (parágrafo único do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a definitivamente em 29 (vinte e nove) dias de prisão simples.

Deixo de aplicar as penas pecuniárias por entender que, na situação aqui analisada, a multa não é suficiente e nem adequada à reprovação das condutas criminosas comprovadas.

Como se viu, há que se entender que o crime de furto simples tentado, os dois crimes de ameaça em concurso formal impróprio e a contravenção penal de vias de fato foram praticados em concurso material, frutos que são de desígnios autônomos. Desta forma, e nos termos do disposto no artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas impostas às infrações penais descritas na denúncia, somatória que alcança 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção e 29 (vinte e nove) dias de prisão simples, bem como 4 (quatro) dias-multa.

Apesar do quantum das penas aplicadas, considerando a reconhecida reincidência e os comprovados maus antecedentes, iniciará o réu o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado; as penas de detenção e de prisão simples se iniciarão em regime semiaberto.

Não havendo informações a respeito de sua situação econômica, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e seu aditamento para condenar SERGIO RICARDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado; 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto; 29 (vinte e nove) dias de prisão simples, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto; e ao pagamento de 4 (quatro) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal; artigo 147 (duas vezes) na forma do artigo 70, parte final, ambos do Código Penal; e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, todos c.c. o artigo 69 do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03,



arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O acusado viu convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. É certo que o fato aqui apurado desassossega a sociedade, compromete a paz social e desequilibra a ordem pública.

Assim, a prisão por sentença condenatória recorrível se revela necessária, seja para assegurar a efetiva aplicação da lei penal, bem como para resguardo da ordem e paz públicas.

Lembre-se que o réu é reincidente por crime de roubo majorado e ostenta maus antecedentes por dois crimes de roubo e por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas). Além disso, fez uso de uma faca para a intimidação das duas vítimas, além de empregar violência contra um dos ofendidos.

Assim, é forçoso reconhecer que essa situação não revela que seja ele pessoa de boa conduta social, mantendo vida desregrada e fazendo da criminalidade e do ataque ao patrimônio alheio seu meio de vida.

Por final, necessário registrar que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para acautelar o procedimento, agora julgado nesta Instância, sendo forçoso reconhecer que, em liberdade, o acusado poderá por em risco a aplicação da lei penal, pois condenado a cumprir pena em gravoso regime.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, pleito formulado pelo Ministério Público a p. 83, ante a ausência de parâmetros para a sua fixação, uma vez que não se produziu prova a esse respeito na instrução criminal.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 16 de novembro de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA